

1505792-07.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos, e também, em razão da forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

É verdade que o acusado negou envolvimento com as 40 porções de cocaína apreendidas pelos guardas civis, mas sua versão não pode ser acolhida.

A esse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505792-07.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505792-07.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO HENRIQUE FERNANDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Rodolfo Henrique Fernandes foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Altamir de Oliveira, em frente ao numeral 363, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações da praça pública do Jardim Ypê, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 40 (quarenta) microtubos de cocaína, pesando 27,8 gramas (vinte e sete gramas e oito decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica e o faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 89), apresentou defesa prévia (fls. 97/98) e a denúncia foi recebida aos 15 de dezembro de 2021 (fls. 99/100).

Houve citação (fls. 119).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu, alegando que a prova produzida é insuficiente para sua condenação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 14); pelo laudo pericial do local (fls. 74/78); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 71/73) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Everton Rodrigo dos Santos disse que estava em patrulhamento e avistou o acusado pegando objeto em um arbusto e escondendo no telhado. Neste momento, quando percebeu a aproximação dos guardas, ele se sentou na calçada do mesmo imóvel. Ele foi submetido a busca pessoal e nada ilícito apreendido, mas, em seguida, o depoente verificou o local onde avistou o acusado e apreendeu as porções de drogas. Tem certeza de que avistou o acusado pegando o objeto no arbusto e escondendo no telhado. O acusado ainda disse ao depoente que, se ele lhe desse uma chance, nunca mais o veria no local. Anteriormente, deteve o acusado por tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Paulo Eduardo Vedovato, acrescentando que outras pessoas foram submetidas à busca pessoal, mas viu claramente o acusado guardando o objeto na calha.

Em solo policial, o acusado Rodolfo Henrique Fernandes disse que estava na casa de sua namorada, que reside próximo ao local onde foi abordado. Disse que foi àquele local para "fumar maconha" e acredita que tenha sido abordado porque um dos GCMS participou de uma prisão anterior do interrogado. Disse que a droga encontrada não é de sua propriedade (fls. 08).

Em juízo, o acusado disse que estava na praça usando droga. Nega que estivesse praticando tráfico de drogas. Disse que a calha mencionada pelos guardas civis está localizada no bar de onde o acusado saiu. Disse que era abordado pelos guardas civis em todo o local em que os encontrava.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos, e também, em razão da forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

É verdade que o acusado negou envolvimento com as 40 porções de cocaína apreendidas pelos guardas civis, mas sua versão não pode ser acolhida.

A esse respeito, anoto que os guardas civis afirmaram que avistaram o acusado pegando objeto próximo a um arbusto e o escondendo no telhado do imóvel, tratando-se de ponto conhecido de venda de drogas.

Nesse contexto, e inexistente qualquer indício de que a versão apresentada pelos guardas civis é mendaz e diversa do que realmente aconteceu, o acusado deve ser condenado como incurso no tipo penal descrito pela denúncia.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal, não havendo necessidade de que fossem flagrados atos de comércio. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Por fim, não há que se falar em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei n. 11.343/06, na medida em que a quantidade de droga apreendida e a forma de embalagem, além de se tratar de ponto conhecido de venda de drogas, a prova é suficiente para a condenação como incurso no artigo 33 da lei n. 11.343/06.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, inexistindo fundamento concreto para o recrudesimento de sua pena, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existe praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, incabível a incidência da causa de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, na medida em que, pouco mais de trinta dias antes do fato aqui apurado, o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33 da lei n. 11.343/06 (autos n. 1500322-59 - fl.93).

Nesse caso, ostentando sentença condenatória prolatada pouco mais de trinta dias antes do fato aqui apurado e, ainda assim, insistindo na prática do crime de tráfico de drogas, notório o envolvimento do acusado em atividades criminosas, não fazendo jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, pois este dispositivo veda a redução da pena do agente que se dedique a atividades criminosas, o que se pode dizer do acusado que, em menos de um ano, foi preso em duas ocasiões distintas pelo crime de tráfico de drogas.

Em hipótese semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: Embora não se tenha notícia de trânsito em julgado, já foi condenado em outro processo por crime da mesma estirpe, circunstância que, aliada à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, delineia ter a narcotraficância como meio de subsistência. E como a 'mens legis' da redutora foi a de beneficiar o agente que tivesse imerso no submundo do crime em situação de mero desvio de conduta, caracterizando o "marinheiro de primeira viagem", como mencionado pela doutrina, não há como conceder a benesse legal na hipótese. O cenário projetado, portanto, revela fatores sintomáticos da dedicação contumaz do réu ao tráfico de drogas, o que fundamenta o afastamento da benesse legal conferida em primeira instância, reconduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso (TJSP, Apelação n. 0002956-24.2010.8.26.0362, 4ª Câmara de Direito Criminal Extraordinária, Relator designado Des. Euvaldo Chaib, julgado aos 7/8/2014).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentir: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agrado regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agrado regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 – SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Rodolfo Henrique Fernandes à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que foi beneficiado com a liberdade provisória no mês de fevereiro de 2021, por força de decisão prolatada nos autos n. 1500322-59 (fls. 93) e, menos de oito meses depois, tornou a ser preso por envolvimento com o tráfico de droga, o que indica que sua liberdade atenta contra a ordem pública, dada a propensão à prática do comércio espúrio. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 20 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA